

1500515-84.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Samir Dancuart Omar

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... de provas em relação ao tráfico e à invasão de domicílio. Também pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em relação à invasão de domicílio, por ter ocorrido em contexto de fuga. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta de tráfico para o artigo 28 da Lei de Tóxicos. No caso de condenação, requereu a aplicação da causa de redução de pena prevista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500515-84.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500515-84.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2104898/2022 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 24355416 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2104898 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2104898/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN GABRIEL VERGUEIRO DOS SANTOS ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Samir Dancuart Omar

Vistos.

1. RYAN GABRIEL VERGUEIRO DOS SANTOS ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), no art. 33, caput, cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei Federal nº. 11.343/2006 e no art. 150, caput, do Código Penal, porque, no dia 17 de abril de 2022, por volta das 18 horas e 50 minutos, na Avenida José Teodoro de Siqueira, nº. 1.131 - Jardim Yolanda, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em concurso com o menor W.S.S. (fls. 05), trazia consigo e guardava, para fins de tráfico de drogas,

332 microtubos contendo cocaína. Consta ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado entrou e permaneceu, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita em casa pertencente a Vinícius Pereira Gomes Nogueira.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, quando avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados com Ryan e o menor W.S.S. (15 anos), correndo em atitude suspeita, logo após perceberem a presença da viatura da Polícia. Iniciada a perseguição, Ryan e o menor adentraram a residência de Vinícius Pereira Gomes Nogueira, sem o consentimento do morador, e permaneceram escondidos neste local, o que motivou os policiais a solicitarem a autorização do morador para ingressarem no domicílio. Com a autorização, dirigiram-se ao interior do imóvel, onde encontraram Ryan e o adolescente no quarto do filho de Vinícius. Com o acusado Ryan foram encontrados 13 microtubos de cocaína e com o menor 96, que havia deixado dentro de uma sacola, ocultada no berço do filho do morador da residência. Indagado pelos policiais, Ryan teria confessado informalmente que haviam terminado o seu turno no tráfico, sendo que o adolescente tentou negociar a liberação deles, indicando a presença de mais 223 microtubos de cocaína, encontrados pelos policiais dentro de uma caixa de luz. Preso em flagrante o acusado foi conduzido a autoridade policial, perante a qual negou a prática da infração.

A denúncia foi oferecida em 19 de maio de 2022 (fls. 88/91).

Após a apresentação da defesa preliminar (fls. 119/120) a denúncia foi recebida no dia 07 de junho de 2022 (fls. 124/128).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas em relação ao tráfico e à invasão de domicílio. Também pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em relação à invasão de domicílio, por ter ocorrido em contexto de fuga. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta de tráfico para o artigo 28 da Lei de Tóxicos. No caso de condenação, requereu a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, facultando ao réu a possibilidade de interposição de recurso em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto.

Ao final da audiência, foi deferida a liberdade provisória ao acusado, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura clausulado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. A ação penal é procedente em parte.

Com efeito, a materialidade delitiva está consubstanciada pelos Autos de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 20/23), Auto de exibição e Apreensão (fls. 27), Exame Pericial em Peças (166/168), Laudo Pericial do Local (176/182), Laudo de Constatação Prévia de Substância Tóxica (fls. 33/36), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 114/116), que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes (cocaína).

A autoria restou igualmente comprovada, a despeito da negativa apresentada pelo réu na delegacia e em juízo.

O réu RYAN GABRIEL VERGUEIRO DOS SANTOS ROCHA, interrogado em solo policial, declarou que estava com uma "pá de molecada fumando um chá" quando policiais militares compareceram no condomínio, momento em que todos saíram correndo. Afirmou que correu até a casa de um morador para se abrigar, mas acabou sendo acompanhado pelo "menino do corre" (Willian). Os policiais adentraram o apartamento e encontraram as drogas do menino. Foi então que o depoente passou a ser agredido fisicamente pelo policial David com socos no rosto e nas costas, pois eles queriam saber onde estavam as demais drogas. Neste momento o "menino do corre" tentou negociar para que parassem de bater neles e fossem liberados. O menino indicou um outro local onde havia mais drogas, mas os policiais não cumpriram com a promessa e prenderam o menino e o interrogando, mesmo não tendo "nada a ver com a drogas". Assegura que não admitiu aos policiais que havia encerrado seu turno na venda de drogas, bem como refutou ter atuado em qualquer forma associativa com o adolescente Willian. Negou que estivesse em posse de 15 microtubos de cocaína quando foi submetido a busca pessoal. Sobre a versão dos policiais de que foi necessário algema-lo porque se comportava de maneira violenta, o interrogado afirma que não se debatia na viatura, apenas estava com câimbra nas pernas e não conseguia dobrá-las para entrar no carro policial. Em juízo, o acusado apresentou basicamente a mesma versão, negando a autoria do tráfico, bem como qualquer vínculo com a droga apreendida na ocasião. Disse que estava sentado fumando e saiu correndo ao ver todos os moleques fugindo com a aproximação da polícia. O menor entrou no apartamento após o depoente. Negou que estivesse com alguma droga em seu poder, com exceção de um cigarro de maconha parcialmente consumido. Não sabe se o menor tinha droga. Os policiais o agrediram quando ainda estavam no quarto, pedindo as drogas. Bateram em sua costela, com "bicudas" e socos. Ficou com marcas e pediu exame de corpo de delito, mas no hospital só deram duas injeções e já voltou para a viatura. Comprou a droga com outra pessoa. Só tinha um baseado em seu poder. Nunca havia visto os policiais que fizeram sua prisão. Disse que conhecia o dono do apartamento, embora não tivesse amizade com ele. Não percebeu que o adolescente estivesse com uma bolsa. O morador acompanhou as buscas. Não demorou muito para ocorrer a abordagem. O policial entrou logo após o menor. É usuário de cocaína também. Estudou até a oitava série. Disse que entrou primeiro no apartamento e que alguns segundos depois o menor entrou. Logo em seguida o policial entrou atrás dele.

O adolescente W.S.S. (fls. 05), ouvido apenas na fase policial, disse que estava no local dos fatos vendendo "pinos de pó" pelo valor de R\$2,00 o microtubo. Aduziu que no momento em que um rapaz (RYAN) foi pegar uma "bucha de erva", ele saiu correndo por ter visto uma viatura da polícia, oportunidade em que também correu e ambos adentraram o apartamento de um morador para se abrigarem. Explicou que não conseguiu dispensar a bolsa com os pinos, sendo que indicou aos policiais onde estava a bolsa com "pó", bem como disse para os policiais que entregaria mais drogas para ser liberado, assegurando que não negociou a liberação de RYAN. Então, indicou uma caixa de luz onde havia ocultado mais drogas - cocaína, em seguida os policiais não cumpriram com a palavra e prenderam o declarante e RYAN que "nada tinha a ver com o negócio". Negou atuar em associação com RYAN, bem como que ele houvesse admitido aos policiais que estava vendendo drogas.

A testemunha VINICIUS PEREIRA GOMES NOGUEIRA, ouvido durante a fase investigatória, declarou que estava com esposa e filho em seu apartamento, quando dois indivíduos que apenas conhece de vista adentraram seu imóvel, sem qualquer autorização e se abrigaram no quarto da criança. Logo depois, policiais militares bateram na porta e solicitaram pelo responsável pelo local, quando o depoente se apresentou. Aduz que os policiais pediram autorização para entrar em sua casa, pois seguiam dois suspeitos em fuga, oportunidade em que o depoente permitiu que adentrassem. Em seguida, os policiais rumaram ao quarto do seu filho, onde abordou os dois rapazes,

Willian e Ryan. Um dos policiais encontrou uma bolsa preta dentro do berço da criança, a qual continha muitas drogas. Aduz o depoente que presenciou o adolescente Willian de posse da bolsa ao adentrar sal casa. Questionado, assegurou que em nenhum momento ofereceu guarida para fuga desses indivíduos, os quais adentraram sua casa sem qualquer consentimento. Indagado se a prisão foi realizada com qualquer forma de excesso, o depoente disse que não.

As testemunhas RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR e DAVID LEMES CORREA DA SILVA, Policiais Militares responsáveis pela prisão do acusado, declararam, na fase de inquérito, que estavam em patrulhamento de rotina, quando, ao trafegar pela Avenida José Theodoro de Siqueira, presenciaram o momento em que dois indivíduos, que estavam defronte ao bloco B do Conjunto Habitacional Santa Isabel do bairro Maria Amélia desta urbe, saíram correndo, tão logo presenciaram a viatura policial – um deles com uma bolsa com a alça no pescoço. Os suspeitos adentraram o Bloco B, quando desembarcaram e os seguiram pelas escadas até eles adentrarem o apartamento de nº 44. Então, o responsável pelo imóvel foi solicitado, oportunidade em que a pessoa de Vinicius Pereira Gomes Nogueira se apresentou e narrou que os suspeitos adentraram sua casa sem qualquer autorização e se abrigaram no quarto do filho. Vinicius autorizou a entrada no imóvel, momento em que abordaram Ryan Gabriel Vergueiro Dos Santos Da Rocha e Willian Da Silva Santo (adolescente). Em busca pessoal, somente com Ryan foram encontrados 13 microtubos de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. No quarto, especificamente no berço do filho de Vinicius, foi encontrado a bolsa que Willian estava de posse durante a fuga, sendo conferido seu conteúdo: 96 microtubos de substância alva aparentando ser cocaína. Indagados, apenas o adolescente admitiu a posse das drogas, inclusive tentou negociar a liberação dele e de Ryan, quando indicou onde havia mais entorpecentes, dentro de uma “caixa de luz”. No local indicado, foi encontrada outra sacola contendo mais 223 microcubos da mesma substância. Ryan apenas se justificou dizendo que o “turno” dele havia terminado e não tinha “nada a ver” com substâncias de Willian. Diante do apurado, ambos vieram conduzidos para esta delegacia de polícia acompanhados do responsável pelo imóvel como testemunha.

Em juízo, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram dois indivíduos que saíram correndo ao visualizar a viatura, um deles com uma sacola a tira-colo. Eles correram para dentro de um apartamento. Foram no encalço dos indivíduos e bateram no apartamento, onde em contato com o proprietário disse que os dois ingressaram sem seu consentimento e estariam no quarto. Eles foram localizados no quarto e foram abordados. Com o réu foram localizados 13 pinos aparentemente cocaína e com o menor de idade não havia nada, mas indicou que estaria no berço da criança uma bolsa contendo mais drogas. Diante da situação eles tentaram negociar a liberdade de Ryan, indicando o restante das drogas. No local indicado, foi localizada uma quantidade maior de droga. Foi dada voz de prisão e conduzidos ao DP. Pelo que se recorda os dois não tinham parentesco. Os dois moravam neste condomínio, mas não no apartamento de Vinicius. Já conhecia de vista o acusado, mas não de envolvimento com outros delitos. Antes de correrem, os dois estavam juntos na frente do bloco. Não se recorda de mais pessoas. É um local que sempre tem movimento. Não percebeu se o réu e o menor estariam consumindo drogas também no local. Informalmente os dois reconheceram a prática do tráfico. Ryan falou que estava no fim do turno dele. Em momento algum houve agressão policial. O menor tentou assumir sozinho para conseguir a liberação de Ryan. Eles estavam na rua na frente do bloco e correram para cima do bloco subindo as escadas até ingressar no apartamento. Não soube precisar quanto tempo decorreu desde o momento em que avistaram o réu e o menor até a abordagem no interior do apartamento. Salvo engano os treze tubos de cocaína foram localizados no bolso da calça.

A testemunha DAVID LEMES CORREA DA SILVA, em juízo, asseverou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, um condomínio da CDHU já conhecido pela prática do tráfico de drogas. Quando adentraram, dois indivíduos correram, um um pouco

menor, com uma bolsa trançada no peito, e outro atrás. Eles correram e entraram em um dos blocos, invadindo um apartamento. Fizeram contato com o moradora que disse que não conhecia os indivíduos e que poderiam adentrar, que eles estariam no quarto. Fizeram a abordagem dos indivíduos e identificaram que se tratava do acusado Ryan, com o qual foram localizados 13 pinos de cocaína, e o outro o menor, que indicou que a bolsa preta com o símbolo do palmeiras estava no berço da criança. O menor informou que eles estavam trocando o turno do tráfico no local e ofereceu que haveria mais drogas em uma caixa de luz em um andar próximo, a fim de conseguir a liberdade de Ryan. Ryan morava no local, porque a mãe dele desceu e foi à delegacia no dia. Não se recorda se o menor morava no prédio. Eles não tinham qualquer relação com os proprietários do apartamento em que se refugiaram. Eles estavam até meio assustados. Não se recorda se eles estavam na companhia de mais pessoas. Nenhum dos dois estava alcoolizado ou drogado, não havendo nenhuma aparência visível de que pudessem estar usando drogas. O menor revelou essas drogas para o depoente e seu colega, mas quem as achou foi o depoente. Não é verdade que tenham agredido os dois. Na época dos fatos estava havendo audiência de custódia. Não havia denúncia, tratava-se de patrulhamento rotineiro em razão da fama do lugar. Durante a fuga, não perceberam nenhum volume nas mãos de Ryan. Eles chegaram a subir alguns andares para entrar no apartamento em que se esconderam. A diligência no apartamento foi bem rápida, pois a moradora já estava na porta, assustada com o ingresso dos indivíduos. O tempo de abordagem foi algo em torno de um minuto e meio. O morador Vinicius acompanhou a abordagem e a busca das drogas. Ryan estava com as drogas no bolso da bermuda.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes e demonstram a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado, em comparsaria com o menor W.S.S..

Os depoimentos dos policiais militares são seguros e harmônicos entre si quando da descrição de toda a operação realizada naquela data, desde o início, em que estavam em patrulhamento ostensivo pelo local e divisaram dois indivíduos correndo ao avistarem a viatura, sendo que um deles carregava uma bolsa, até o momento da abordagem, no interior do apartamento da testemunha Vinicius, quando houve a localização do entorpecente e a ordem de prisão em flagrante.

Com efeito, ambos os policiais disseram que ao avistar dois indivíduos correndo em razão da aproximação da viatura, um deles com uma bolsa a tira-colo, desembarcaram e seguiram tais indivíduos até que estes adentraram em um apartamento, oportunidade em que o responsável pelo imóvel foi solicitado e confirmou o ingresso em sua casa sem autorização. Ato contínuo, autorizados pelo morador, ingressaram no apartamento e lograram deter o réu e o adolescente que o acompanhava no quarto.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso do réu 13 microtubos de cocaína. Também foi encontrado dentro de um berço a bolsa que estava com o Adolescente durante a fuga, contendo em seu interior 96 microtubos de cocaína. Ainda segundo os policiais, nesse momento o adolescente tentou negociar a liberdade de Ryan e, para tanto, indicou que havia mais drogas guardadas, indicando o local, onde foram localizados mais 223 pinos de cocaína.

O relato dos policiais revela-se perfeitamente condizente com o depoimento do proprietário do imóvel onde o acusado e o adolescente foram encontrados homiziados, após breve fuga, o que reforça sua credibilidade.

Com efeito, Vinicius não somente confirmou o ingresso dos dois em seu apartamento sem autorização, como também informou que o adolescente trazia a tira-colo uma bolsa, que foi localizada pelos policiais, constatando-se que nela havia drogas.

Como se isso não bastasse, a dinâmica descrita pelos policiais foi inclusive

admitida pelo próprio acusado RYAN e pelo adolescente, no que diz respeito à fuga após perceberem a aproximação da polícia, ao ingresso no apartamento de Vinicius sem autorização e à abordagem policial ocorrida no quarto, ocasião em que a bolsa fora apreendida.

Por outro lado, as versões defensivas apresentadas pelo réu e pelo adolescente, no que diz respeito a não vinculação de RYAN ao tráfico, não convencem, por estarem isoladas do conjunto probatório e por não serem minimamente verossímeis.

A alegação do réu RYAN de que fora vítima de violência policial não encontra amparo em nenhuma prova concreta produzida nos autos, valendo notar que o exame de corpo de delito realizado por ocasião de sua prisão não constatou a existência de qualquer lesão (fls. 77/78).

Também não há como acreditar na alegação de RYAN de que estaria fumando maconha no momento da chegada dos policiais, pois ela está em contradição com o próprio relato do adolescente, segundo o qual Ryan estaria comprando dele uma "bucha de erva", no momento da chegada dos policiais. Ora o acusado afirmou expressamente que não havia comprado entorpecentes do adolescente naquele dia, a evidenciar a fragilidade dos dois relatos.

Resta evidente, pois, que nenhum dos dois falou a verdade, tanto que sequer foi apreendida maconha na ocasião, mas apenas e tão-somente cocaína, conforme se infere do auto de exibição e apreensão e laudos juntados aos autos.

Também não se justificaria a fuga empreendida pelo réu, se de fato fosse simples usuário, portando um baseado de maconha, como alegado em interrogatório, porquanto é de conhecimento geral que tal crime é de menor potencial ofensivo, não ensejando sequer a prisão de quem o pratica.

Na realidade, o que se infere dos relatos firmes e convincentes dos policiais e com base nas próprias circunstâncias que restaram incontroversas nos autos, é que o acusado e o adolescente fugiram ao visualizar a aproximação da viatura, porque ambos estavam praticando o tráfico de entorpecentes em concurso de agentes.

A apreensão de maior quantidade de entorpecentes na bolsa que o adolescente trazia a tira-colo durante a fuga coaduna-se perfeitamente com a informação dada informalmente aos policiais por RYAN de que estaria ocorrendo a troca de turno naquele momento. Assim, é bem provável que tenha sido transferida a guarda da maior parte das porções de RYAN para o adolescente que assumiria o turno do tráfico a partir de então. RYAN poderia ter ficado com a quantidade inferior de drogas, as 13 porções, em seu bolso, até mesmo como remuneração pelo trabalho realizado.

A fuga para o mesmo local também constitui indício concreto da existência de vínculo associativo entre o acusado e o adolescente RYAN, uma vez que seria muito pouco provável que escolhessem o mesmo ponto de refúgio em uma fuga que fosse verdadeiramente aleatória.

Por fim, a tentativa do adolescente de assumir sozinho a propriedade da droga isentando o acusado não surpreende, considerando que se trata de expediente corriqueiro no mundo do crime, com o propósito de impedir ou obstar a aplicação da Justiça aos imputáveis, sujeitos a sancionamento mais rigoroso.

O fato de o acusado não ter sido visto durante a fuga com volume sob as vestes ou trazendo qualquer objeto em suas mãos não o isenta da responsabilidade pelo crime, tampouco fragiliza a prova acusatória, na medida em que as 13 porções de cocaína que trazia estavam guardadas em seu bolso, passando assim despercebidas durante a rápida perseguição.

A menção de Vinicius à localização pelo policial da mochila contendo muitas drogas no berço do quarto de seu filho, sem fazer referência a apreensão das 13 porções com o acusado, não pode ser interpretada como evidência da inocência do réu, porquanto não exclui a ocorrência desta apreensão.

Também não é incoerente o fato de o réu não ter se desfeito das drogas durante a fuga, porquanto tudo ocorreu muito rápido, impedindo a adoção de qualquer medida tendente a obliterar a prova da materialidade da infração. Nesse sentido reconheceu o próprio réu, ao afirmar que os policiais ingressaram no apartamento poucos segundos após o adolescente, o que certamente impediu qualquer tentativa de ocultação ou desfazimento da droga.

Não pode deixar de ser mencionado, outrossim, que os Policiais Militares são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar o réu. Repita-se que o réu declarou expressamente em seu interrogatório que não conhecia os policiais que atuaram nesta ocorrência, os quais não teriam, obviamente, interesse em acusa-lo de um delito desta gravidade se de fato fosse inocente.

Nesse sentido: "Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quanto estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes" (TACRIM-SP, Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80).

"Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação" (TJSP - AP - 1ª C. - Rel. Marcial Holanda - j. 10.04.95 - RT 721/414). (in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, Rui Stoco e outros, editora RT, 1999, volume 2, págs. 1833/1835).

Assim, a prova é segura e autoriza o decreto condenatório contra o acusado por crime de tráfico de entorpecentes, incidindo, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, uma vez que o crime envolveu o adolescente W.S.S.

Destaque-se que a quantidade de porções apreendida revela-se incompatível com a posse para uso próprio, indicando de forma clara a destinação ao comércio ilegal de entorpecentes.

Ainda que se admitisse a condição de usuário do acusado, o que não restou suficiente comprovado, tal não impediria o reconhecimento do crime a ele imputado, porquanto não é incomum a prática do comércio ilegal como forma de sustentação do vício.

Prejudicado, conseqüentemente, o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Tóxicos veiculado pela Douta Defesa.

Com relação à imputação de invasão de domicílio, contudo, impõe-se a absolvição, por atipicidade da conduta, uma vez que o ingresso na residência de Vinicius teria ocorrido no contexto de fuga da polícia, a excluir o dolo exigido para a configuração do delito.

Neste sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FATO PRATICADO EM CONTEXTO DE FUGA DA POLÍCIA, LOGO APÓS COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão, a conduta de invasão de domicílio pelo acusado constituiu pos factum impunível, porquanto o réu teria adentrado na residência da vítima tão somente para fugir da abordagem policial após a prática dos crimes de roubo. 2. Considerando a fuga engendrada e, não havendo, por parte do acusado, a intenção de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, não há falar em condenação pelo crime do art. 150, § 1º, do CP. 3. O acolhimento da pretensão ministerial, de forma a restabelecer a condenação, exigiria revolvimento fático-probatório com o fim de verificar a existência do dolo do agente, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.801.919/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2019 Sem ênfase no original).

Na mesma linha também se pronunciou o E. Tribunal Bandeirante, conforme acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – Sentença condenatória quanto ao tráfico e absolutória no tocante à violação de domicílio – Insatisfação ministerial – Pedido de condenação no que se refere ao crime disposto no art. 150, §1º, do CP – Inviabilidade – Ausência de dolo – Conduta de ingresso em domicílio alheio praticada em contexto de fuga policial – Não verificação de dolo – Precedentes do STJ e TJSP – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas quanto ao tráfico – Afastamento da incidência do redutor inculcado no §4º do art. 33 da Lei de Drogas – Necessidade – Cotejo entre o registro de ato infracional e a quantidade de entorpecentes apreendidos que justifica a não incidência da minorante em tela – Fixação de regime fechado – Pertinência – Conduta concretamente grave, envolvendo tráfico de significativa quantidade de cocaína, de poder vulnerante acentuado – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1503442-04.2021.8.26.0279; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

A procedência parcial da pretensão punitiva do Estado, com a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, c.C. Artigo 40, inciso IV, da Lei de Tóxicos e absolvição em relação ao delito do artigo 150, caput, do Código Penal, constitui medida de rigor.

4. Passo à dosimetria das penas, na forma estabelecida pelo artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06, fixo a pena acima do mínimo legal, majorando-a em 1/12, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, com peso líquido total de 247,82 gramas de cocaína, divididas em 332 microtubos, a revelar maior reprovabilidade da conduta. Assim, a pena-base é fixada em 05 anos e 05 meses de reclusão e 541 dias-multa, com valor fixado no mínimo (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Na segunda fase de aplicação da pena reconheço a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6, fazendo-a assim retornar ao mínimo legal, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de adolescente na empreitada criminoso), aumento a

reprimenda acima cominada em mais 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Ainda na terceira fase revela-se cabível a aplicação da causa de redução de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006, uma vez que o acusado é primário, não ostenta maus antecedentes e inexistem indícios de que integre organização criminosa ou que se dedique de forma reiterada a atividades criminosas. Considerando, contudo, a quantidade de entorpecente apreendida, justifica-se a redução em percentual intermediário, correspondente a 1/2, perfazendo, assim, um total de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, que resta fixada em definitivo, à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas.

Quanto à fixação do regime para cumprimento da pena corporal imposta, a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012).

Portanto, o acusado deve iniciar o cumprimento da pena reclusiva em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal. Registro que a quantidade das drogas, já considerada na primeira fase de aplicação da pena, não revela incompatibilidade com o regime mais brando, consideradas as demais circunstâncias favoráveis ao réu.

Finalmente, considerando a quantidade de pena aplicada, o fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça e por ser o réu primário, perfeitamente possível a aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal.

Assim, substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, e pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do artigo 44, §2º do Código Penal, sem prejuízo das outras penas aplicadas.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva do Estado para: 1) CONDENAR o réu RYAN GABRIEL VERGUEIRO DOS SANTOS ROCHA, como incurso no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei. 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, e por outros 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal; e 2) ABSOLVÊ-LO em relação ao delito descrito no artigo 150, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em face da substituição operada, defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena e procedam-se as comunicações necessárias, arquivando-se, oportunamente.

Custas "ex lege", observando-se a Justiça Gratuita.

P.I.C.

Jacarei, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA